

1507630-75.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... legal. A esse respeito: "O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507630-75.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507630-75.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2330489/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 21776999 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 3435/21/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2330489 - DEL.POL.SALTO, 3435/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS, por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06 c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, em tese, no dia 05 de dezembro de 2021, por volta das 22h13min, na Rua Marques de Barbacena, nº 43, Parque Residencial Mal Rondon, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, o acusado, durante período de calamidade pública, guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 66 (sessenta e seis) porções de "cocaína", com peso líquido de 27,18g (vinte e sete gramas e dezoito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 10 de janeiro de 2022 (fls. 67-71) .

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa prévia (fls. 82-83).

A denúncia foi recebida em 22 de fevereiro de 2022 (fl. 104-108).

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas comuns.

A preliminar de ilegalidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais e nulidade da prova por violação de domicílio, bem como pedido de absolvição sumária foram apreciados e afastados pela decisão de fls. 104-108, que transitou em julgado.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e fixação do regime fechado. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado, formulando pedido subsidiário de aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.07-09), auto de exibição e apreensão (fl.12), auto de constatação preliminar (fls.13) e laudo de exame químico toxicológico (fls.72-74), bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais, Antônio Alessandro Frois e Thiago Martins testemunhas comuns, relataram em juízo, em resumo, que estavam em patrulhamento quando um indivíduo relatou que é morador da Rua Marquês de Barbacena e em tal rua, André estaria, naquele momento, comercializando entorpecentes na calçada. No local indicado, encontraram o réu e efetuaram a abordagem. Questionado, ele negou que estivesse traficando, porém, disse que no interior de sua casa havia certa quantidade de drogas destinada a venda. O réu franqueou a entrada na residência e entregou 66 (sessenta e seis) microtubos de cocaína que estavam guardados no guarda-roupa. Explicou que utilizou quinhentos reais para comprar a cocaína à granel, a transformando nas porções para venda. Daniele, esposa do acusado, acompanhou as buscas pelas drogas pela casa e afirmou que não sabia sobre a existência do entorpecente.

O réu, interrogado judicialmente disse, em resumo que é usuário de drogas. Não estava praticando o tráfico de drogas no momento da abordagem. Mantinha a droga na residência por ordem dos traficantes locais, a fim de abater o valor de uma dívida. A esposa dele não sabia de nada.

Os guardas municipais apresentaram versão coerente, demonstrando que o réu guardava e tinha em depósito para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, 66 (sessenta e seis) porções de "cocaína", com peso líquido de 27,18g (vinte e sete gramas e dezoito centigramas), com o intuito de comercialização. Além disso, o réu confessou o crime, incorrendo na modalidade "manter em depósito".

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilicitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada de R\$ 40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62

gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômulo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021). Em que pese o réu alegar que não iria comercializar o entorpecente, o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, restou demonstrado que guardava e tinha em depósito para venda, ainda que por terceiro, a cocaína acondicionada de forma fracionada, devendo ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito: "O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes com a recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminoso e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável. Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram

devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido" (TJSP: Apelação Criminal 1512067-20.2020.8.26.0228; Relator (a): ANDRADE SAMPAIO; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Barra Funda, 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021). De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No presente caso, o réu é reincidente específico (vide fls. 39-40, processo (0000666-78.2016.8.26.0571), sendo preso em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas em 05 de dezembro de 2021, ou seja, pouco mais de seis meses após ser concedido o livramento condicional naqueles autos, evidenciando, assim, seu engajamento no comércio clandestino de drogas, circunstância impeditiva da aplicação do privilégio, uma vez que não preenchidos todos os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Na fase do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é normal à espécie; não há elementos para valorar negativamente a personalidade e conduta social do acusado; o motivo é normal à espécie; as circunstâncias e consequências do crime não podem ser valoradas negativamente, réu é portador de maus antecedentes, mas serão valorados como reincidência (vide fls. 39-40), razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase da fixação da pena presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantenho a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes causa de diminuição e aumento, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Diante da reincidência e quantidade de pena aplicada, o regime inicial será o semiaberto, conforme artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, observada a súmula 269 do STJ.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e incompatível com o benefício da suspensão da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 e do 77 a 82, todos do CP.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Também levando em consideração que o réu é reincidente específico, respondeu ao processo preso, há perigo concreto de reiteração delitiva, razão pela qual nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Comunique-se, desde logo, a penitenciária em que se encontra recolhido ou, se necessário, expeça-se mandado de prisão.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB -Defensoria/SP ao advogado dativa, para retirada exclusivamente pela internet.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se e intime(m)-se

Salto, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA